

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제02절 항소의 제기>

[기출][2023-3]부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

《【문제3】 부대항소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

I. 문제의 제기

- 부대항소란 항소를 당한 피항소인이 항소인의 항소에 의하여 개시된 항소심 절차에 편승하여 자기에게 유리하도록 제1심 판결을 변경할 것을 구하는 신청을 말한다.(민사소송법 제403조) 이는 항소권이 소멸하여 독립하여 항소를 할 수 없는 상태라 하더라도, 상대방이 항소를 제기해 온 이상 공평의 원칙상 피항소인에게도 불복의 기회를 부여하기 위한 제도이다. 또한 불이익변경금지의 원칙을 깨뜨리고 항소심의 심판 범위를 피항소인이 불복하는 범위까지 확장시키는 기능을 한다. 이하에서는 부대항소의 적법 요건과 구체적인 행사 방법 및 그 효력에 대해 설명한다.

II. 부대항소의 요건

1. 주된 항소가 적법하게 계속 중일 것

- 부대항소는 주된 항소에 의존하는 종된 권리이므로, 주된 항소가 적법하게 제기되어 항소심에 계속 중이어야 한다. 만약 주된 항소가 부적법하여 각하된다면 부대항소 역시 그 효력을 잃게 된다.

2. 피항소인이 항소인을 상대로 제기할 것

- 부대항소는 피항소인이 항소인을 상대로 제기하여야 한다. 통상적인 항소심 절차의 당사자 사이에서 이루어지며, 보조참가인이 피참가인을 위하여 부대항소를 하는 것도 허용된다.

3. 항소심의 변론종결 전까지 제기할 것

- 부대항소는 항소심의 변론종결 전까지 제기하여야 한다. 독립된 항소와 달리 항소기간의 제한을 받지 않으므로, 자신의 항소기간이 도과하거나 항소권을 포기한 후라도 항소심 변론종결 전이라면 언제든지 제기할 수 있다.

III. 부대항소의 절차와 방식

1. 부대항소장의 제출

- 부대항소는 항소에 관한 규정에 따라 부대항소장을 항소심 법원에 제출함으로써 한다. 부대항소장에는 부대항소의 취지와 이유를 적어야 하며, 독립된 항소장과 마찬가지로 인지를 첨부하여야 한다.

2. 불복 범위의 기재

- 부대항소인은 제1심 판결 중 자신에게 불리하게 판결된 부분에 대하여 어느 범위까지 변경을 구하는지 명확히 기재하여야 한다. 이에 따라 항소심의 심판 범위가 확장된다.

IV. 부대항소의 효력

1. 불이익변경금지 원칙의 배제

- 원칙적으로 항소심은 항소인의 불복 범위 내에서만 심판하며 항소인에게 불리하게 판결을 변경할 수 없으나, 부대항소가 제기되면 법원은 피항소인이 불복한 범위까지 심판할 수 있게 된다. 결과적으로 항소인에게 제1심보다 불리한 판결이 내려질 수 있다.

2. 주된 항소와의 종속성

- 부대항소는 주된 항소가 취하되거나 부적법하여 각하된 때에는 그 효력을 잃는 것이 원칙이다.(민사소송법 제404조 본문)

(1) 예외 : 독립항소 요건을 갖춘 경우

- 다만, 부대항소가 항소기간 내에 제기되어 독립된 항소로서의 요건을 갖추고 있는 경우에는 주된 항소가 취하되더라도 독립된 항소로 보아 그 효력이 유지된다.(민사소송법 제404조 단서)

(2) 상계항변과 부대항소

- 최근 판례는 상계항변이 인용되어 승소한 피고가 원고의 항소에 대하여 부대항소를 제기하지 않더라도, 항소심에서 다시 상계항변을 유지하거나 반대채권의 존부를 다투는 것은 부대항소 없이도 가능하다고 보아 피항소인의 방어권을 존중하고 있다.

V. 특수한 형태의 부대항소

1. 가집행선고만을 구하는 부대항소

- 제1심에서 가집행선고가 불지 않은 경우 피항소인은 항소심에서 가집행선고만을 구하기 위한 부대항소를 제기할 수 있다.

2. 예비적 부대항소

- 주된 항소가 인용될 것을 대비하여 예비적으로 제1심 판결의 변경을 구하는 형태의 부대항소도 가능하다.

VI. 결론

- 부대항소는 항소심 절차에서 당사자 간의 실질적인 형평을 기하고 분쟁을 일거에 해결할 수 있게 하는 유용한 제도이다. 특히 항소권이 소멸한 피항소인에게 다시금 불복의 기회를 제공함으로써 처분권주의와 공평의 원칙을 조화시킨다. 법원은 부대항소의 종속성과 심판 범위 확장 효과를 정확히 파악하여, 주된 항소의 운명에 따른 부대항소의 처리에 유의하여야 하며 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 운영하여야 한다.